

0000471-49.2014.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... em caso de haver outros elementos probatórios:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000471-49.2014.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000471-49.2014.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 23/2011 - Delegacia de Polícia de Neves Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alfredo Aparecido Arantes

Justiça Gratuita

Vistos.

ALFREDO APARECIDO ARANTES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por quatorze vezes no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, entre os dias 08 e 10 de fevereiro de 2011, em horário incerto, na Rua 21 de Abril, nº 187, Centro, Neves Paulista, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Elisa Mara de Oliveira e com outras pessoas não identificadas, obteve, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima P.P.M., induzindo em erro terceiras pessoas, mediante o emprego de meio fraudulento.

Depreende-se da exordial, que no dia 08 de fevereiro de 2011, Elisa foi até a residência de P., pessoa que lhe era desconhecida, e lhe pediu dinheiro. Ele deu a ela algum dinheiro, não se recordando o quanto. Elisa, aproveitando-se da distração

da vítima, furtou seu cartão e senha, que estavam juntos.

Assim, no dia 09 de fevereiro de 2011, de posse do cartão do banco e da senha, Elisa, Alfredo e os indivíduos não identificados realizaram três empréstimos bancários, nos valores de R\$ 1.000,00 (mil reais), R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e R\$ 1.000,00 (mil reais), na conta corrente da vítima. Na sequência, Elisa efetuou duas transferências, uma de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e outra de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para sua conta pessoal de conta poupança n.º 5242-8, agência 6688, da cidade de Guairá.

Após, Elisa, Alfredo e os indivíduos não identificados se dirigiram à cidade de Monte Aprazível onde efetuaram três saques no caixa eletrônico da agência local, sendo dois no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e um no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Em seguida, realizaram compras no comércio local, nos seguintes estabelecimentos:

1) "Lojas Longo", sendo duas compras, uma no valor de R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) e outra no valor de R\$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais); 2) "A Paulistana Tecidos", uma compra de R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais) e; 3) "Cergatti", sendo duas compras, sendo uma no valor de R\$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) e outra de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Por fim, no dia 10 de fevereiro de 2011, Elisa, Alfredo e os indivíduos não identificados ainda, efetuaram mais dois saques da conta da vítima, sendo ambos no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). Os fatos ocorreram na agência 0031, na cidade de Barretos, que fica próxima a cidade de Guairá, local onde mora a denunciada Elisa. O prejuízo sofrido pela vítima totalizou R\$ 14.708,00 (quatorze mil, setecentos e oito reais).

Narra a denúncia que Elisa e Alfredo se utilizaram de meio fraudulento na medida em que fizeram os funcionários das lojas acreditar que haviam obtido a posse e a senha do cartão bancário da vítima de forma lícita. Da mesma forma procederam quando realizaram as transações bancárias.

A denúncia foi oferecida em 29.06.2012 (fls. 168/169) e recebida em 15.08.2012 (fls. 170/171).

Após várias tentativas frustradas de localização do réu, houve sua citação por edital às fls. 241.

Apresentada resposta à acusação às fls. 249.

Determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 20.05.2014, através da decisão de fls. 250, bem como o desmembramento do processo com relação ao réu Alfredo Aparecido Arantes, por não ter sido localizado, prosseguindo-se com relação a ele neste feito.

Após várias tentativas de localização do réu, foi juntada sua procuração às fls. 518, espontaneamente pelo seu defensor constituído, que não informou atual endereço do réu (fls. 533).

Revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls.538).

Resposta à acusação apresentada às fls. 546/555, com a alegação preliminar de nulidade do processo por ausência de representação por parte da vítima e inépcia da denúncia, por conter a exposição genérica dos fatos. No mérito, alegou a inocência do réu.

O recebimento da denúncia restou mantido por não ocorrer qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária (fls. 568).

Vinda de Folha de Antecedentes criminais do réu às fls 620/641.

Durante a audiência de instrução e julgamento de fls. 642/644, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas de acusação, três testemunhas comuns e uma testemunha de defesa. Em razão da ausência do réu, foi decretada sua revelia.

Em alegações finais ministeriais de fls. 647/652, houve o pedido de procedência da ação. A combativa defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 660/681, alegou a injusta revelia aplicada ao réu e a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De saída, assinalo que diante das infrutíferas tentativas de citação pessoal do réu

Alfredo, a decisão de fls. 250 determinou o desmembramento do feito original de n. 0000275-84.2011.8.26.0382, com relação a ele, prosseguindo aquele feito com relação a ré Elisa Mara de Oliveira. Assim, houve a instauração deste processo desmembrado de n. 0000471-49.2014.8.26.0382, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Os autos somente retornaram ao andamento após decisão de fls. 538, com a vinda voluntária do procurador constituído do réu (fls. 518).

Adiante, passo a analisar as preliminares arguidas.

A alegação de ausência de representação por parte da vítima não vinga.

De acordo com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vigente desde 23 de janeiro de 2020, a ação penal para apuração do crime de estelionato passou, em regra, a ser condicionada à representação.

Todavia, a referida Lei 13.964/2019, trouxe exceções nos incisos I a IV. Assim, de acordo com o inciso IV, a ação será incondicionada se a vítima for maior de 70 anos, como no caso dos autos, pois na época a vítima tinha 87 anos de idade. Por tal, desnecessária a representação do ofendido.

No tocante à arguição de inépcia da denúncia, não há que se cogitar na falta de condição da ação. A peça acusatória descreveu claramente os fatos delituosos, com todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada ao acusado, propiciando-lhe o pleno exercício do direito de defesa.

No mais, as arguidas nulidades processuais, diante da alegada injusta revelia decretada, bem como frente ao reconhecimento fotográfico, não prosperam, como se verá no decorrer da fundamentação da presente decisão, quando serão afastadas.

No mérito, a ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Transcrevo o tipo penal de estelionato indicado na denúncia:

"Artigo 171, caput, - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa".

A materialidade e a autoria dos delitos estão parcialmente consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Relatório de Investigação (fls. 11/27), Reconhecimentos Fotográficos (fls. 65, 67 e 69), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Com efeito, o delito de estelionato é caracterizado pela fraude e consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano. O crime requer a cooperação da vítima, pois o início de sua execução se dá com o engano da vítima.

Ou seja, consegue-se um benefício ou lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima e essa colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus bens.

Para ser caracterizado como crime de estelionato, todas as características do tipo devem estar inclusas pois, elas são os elementos constitutivos do referido crime.

Mencionadas estas assertivas, passo a transcrever a prova oral colhida :

A vítima, ouvida apenas em sede policial, pois faleceu no ano de 2013 (fls. 605), relatou que por volta do dia 08.02.2011 estava em sua residência quando por lá chegou uma mulher desconhecida, pele branca, aparentando ter aproximadamente quarenta e três anos, de compleição física forte, com um dos braços enfaixados, pedindo dinheiro. Entregou dinheiro a mulher, não se recordando o valor. No dia 11.02.2011, procurou seu cartão do Banco do Brasil, mas não o localizou no bolso de sua camisa, onde havia deixado junto com a senha. Foi até a agência local e, em conversa com o gerente Fábio, este lhe informou que indivíduos desconhecidos haviam efetuado vários empréstimos, transferências, compras e saques em sua conta corrente, nos dias 09 e 10 do mês de fevereiro. Foi efetuado o bloqueio de sua conta corrente e elaborou um Boletim de Ocorrência. Após os fatos, contratou uma pessoa para ficar com ele no período da manhã e outra para pernoitar, também não deixa mais as portas da residência destrancadas. Somando todos os empréstimos e transações efetuadas, acredita que o prejuízo sofrido tenha sido em torno de R\$ 30.000,00 (fls. 90).

A testemunha Fábio Pastore Rodrigues, funcionário do Banco do Brasil na época dos

fatos, em fase policial, informou que por volta do dia 11 de fevereiro de 2011 foi procurado pela vítima, informando que seu cartão do banco havia sido furtado. Tirou um extrato da conta corrente do ofendido, tendo verificado que indivíduos desconhecidos haviam efetuado várias movimentações financeiras em sua conta corrente, nos dias 09 e 10 de fevereiro, sendo elas empréstimos, saques, transferências e compras na função débito. Efetuiu o bloqueio do cartão da conta corrente, solicitando que fosse elaborado um Boletim de Ocorrência acerca dos fatos (fls. 92). Em juízo, confirmou os fatos narrados em sede policial. Disse que o ofendido lhe informou que teria aparecido uma mulher com o braço engessado em sua residência, que acabou o enrolando e furtando seu cartão e senha. Não se recorda das transações efetuadas, nem os valores, mas se recorda de que tinham feito até empréstimo no nome da vítima. Na época dos fatos, não tinha câmera de segurança no Banco. Não se recorda do prejuízo sofrido pela vítima. Indagado, respondeu que não se recorda do ofendido ter relatado se havia alguém acompanhando a mulher que adentrou em sua residência (fls. 644).

A testemunha José Rodrigo Tonon, investigador de polícia, responsável pela elaboração do relatório de fls. 11/12, em juízo, relatou que na época dos fatos foi constatado que os indivíduos que se apossaram do cartão e senha da vítima, primeiramente efetuaram transferência de valores para uma conta em Guaíra, de titularidade de Elisa. Em seguida, constataram que houve várias compras no comércio de Monte Aprazível. Em contato com policiais da cidade de Guaíra, eles forneceram imagens de Elisa e Alfredo. Percorreu as lojas de Monte Aprazível, ocasião em que os funcionários identificaram as pessoas de Elisa e Alfredo. Esclareceu que, segundo relatos da vítima, alguém teria furtado seu cartão e senha. No banco, o ofendido constatou que alguém havia efetuado compras, empréstimos e transferências com seu cartão. Ele não se lembrava de quem poderia ter furtado seu cartão, já era de idade avançada. Não se recorda do ofendido ter relatado sobre uma mulher que teria adentrado a sua residência pedindo dinheiro. Informou que no comércio de Monte Aprazível Elisa e Alfredo entraram em três lojas. Em uma delas, tinha filmagens de uma pessoa com o braço enfaixado, que correspondia a Elisa. Nas filmagens, além de Elisa, aparecia também mais um homem e uma mulher. Os funcionários da loja Cergatti reconheceram Alfredo, que teria adentrado a loja para comprar um tênis. Eles disseram que Alfredo estava de posse do cartão, acompanhado de uma pessoa que não era Elisa. Segundo os funcionários, Alfredo não efetuou a compra, diante dos questionamentos sobre a titularidade do cartão. Os funcionários reconheceram o réu através de fotografias, obtidas com a delegacia de Guaíra, de onde Alfredo e Elisa já eram conhecidos pela prática de estelionatos. Os funcionários da loja reconheceram Alfredo. Elisa foi reconhecida através de foto do próprio sistema do Banco. Ela fez, inclusive, transferência para sua própria conta. Sobre o telefone que consta em seu relatório, não foi apurado de quem seria. Indagado, esclareceu que foram apresentadas também outras fotos para os funcionários da loja, mas eles não reconheceram (fls. 644).

A testemunha Maiza Arnais Miani, na delegacia de polícia, relatou que trabalha na loja Cergatti, de Monte Aprazível, na função de caixa. Toda vez que uma pessoa efetua uma compra na loja, quando o pagamento é feito por cartão com senha, não é exigido documento pessoal. Por norma da loja, quando não tem a senha do cartão, é obrigatória a apresentação dos documentos pessoais. No dia do fato estava trabalhando na loja quando adentrou uma senhora e dois rapazes. Eles compararam calçados e meias e efetuaram o pagamento através de cartão de crédito. A loja não teve qualquer tipo de prejuízo. Informou as características da mulher: gorda, morena, cabelo preto, aproximadamente quarenta anos de idade, e as dos rapazes, sendo um deles baixo e moreno, e o outro alto, claro, porte físico avantajado e aparentando ter quarenta anos de idade (fls. 64). Em juízo, recordou-se do fato e disse que quem passou o cartão foi o homem, mas não se recorda da fisionomia deles. Não se recorda se na época dos fatos reconheceu o homem. Na delegacia, foram apresentadas fotografias. Acredita que na época tenha se lembrado deles, mas hoje não se recorda mais. A respeito do reconhecimento fotográfico de fls. 65, confirmou ter reconhecido o réu na delegacia, porque os fatos eram muito recentes. Indagada, disse que quando foi efetuar o reconhecimento fotográfico, acredita que foram

apresentadas outras fotos de outras pessoas, homens e mulheres (fls. 644).

A testemunha Claudia Maria Alipio Peredo, em sede policial, relatou que trabalha na loja Cergatti, de Monte Aprazível, na função de vendedora. Atendeu o indivíduo da foto juntada na carta precatória e uma moça de cor morena, estatura média, cabelo preto e comprido. Toda vez que uma pessoa efetua compra e paga com cartão que tem senha, não é exigido documento pessoal. Por norma da loja, quando não tem a senha do cartão, é obrigatória a apresentação dos documentos pessoais. No dia do fato estava trabalhando na loja, quando adentrou uma senhora e dois rapazes. Eles compraram calçados e meias e efetuaram o pagamento com cartão de débito. A loja não teve prejuízo. Informou as características da mulher: gorda, morena, cabelo preto, aparentando ter quarenta anos de idade, e as dos rapazes, sendo um deles baixo e moreno, e o outro alto, claro, porte físico avantajado, aparentando ter quarenta anos de idade (fls. 66). Em juízo, não se recordou dos fatos. Confirmou ter assinado o termo de depoimento de fls. 66 e o termo de reconhecimento fotográfico de fls. 67 (fls. 644).

A testemunha Jucileia Alves de Lima, em sede policial, relatou que trabalha na loja Cergatti, de Monte Aprazível, na função de vendedora. Atendeu o indivíduo da foto juntada na carta precatória, quando ele deixou sua colega e pediu para ela mostrar alguns pares de meia. Toda vez que uma pessoa efetua compra e paga com cartão que tem senha, não é exigido documento pessoal. Por norma da loja, quando não tem a senha do cartão, é obrigatória a apresentação dos documentos pessoais. No dia do fato estava trabalhando na loja, quando adentrou dois rapazes, inclusive o da foto, acompanhado de uma senhora. Eles compraram calçados e meias e efetuaram o pagamento com cartão de débito. A loja não teve prejuízo. Informou as características da mulher: gorda, morena, cabelo preto, aparentando ter quarenta anos de idade, e as dos rapazes, sendo um deles baixo e moreno, e o outro alto, claro, porte físico avantajado, aparentando ter quarenta anos de idade (fls. 68). Em juízo, recordou que o rapaz estava acompanhado de uma mulher, e que fizeram a compra e foram embora. Posteriormente, soube que o cartão era roubado. Afirma que foi até a delegacia fazer o reconhecimento fotográfico. Confirmou que foi ouvida na delegacia e que assinou as declarações. Indagada, informou que foi o homem quem efetuou o pagamento das compras (fls. 644).

A testemunha Orlando Maia Júnior afirmou não conhecer o réu. Sobre os fatos, tem conhecimento de que eles compraram nas lojas "Longo", "Paulistana" e "Cergatti". O pagamento foi efetuado através de cartão de débito. As lojas não tiveram prejuízo. Sabe que o cartão era produto de furto. As pessoas foram identificadas pelos funcionários da loja Cergatti, os quais reconheceram a pessoa que passou o cartão de crédito (fls. 644).

O réu permaneceu em silêncio na fase extrajudicial (fls. 151). Em juízo, teve decretada a revelia (fls. 642/643).

Com efeito, o conjunto probatório apresentado é suficiente para embasar um decreto condenatório.

No entanto, não restaram comprovados os 14 (quatorze) delitos de estelionato como indicado na denúncia, mas apenas a prática pelo réu, de 02 (dois) delitos, como a seguir explicitado.

Através dos fatos e provas trazidos aos autos, comprovou-se que no dia 08 de fevereiro de 2011, a vítima teve seu cartão do Banco do Brasil furtado, bem como sua senha, pela ré Elisa Mara de Oliveira, que foi até a residência da vítima para lhe pedir dinheiro, praticando o furto, aproveitando-se da distração da vítima. Em seguida, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2011, na conta bancária da vítima houve a realização de três empréstimos bancários, duas transferências de valores, cinco saques em caixa eletrônico e compras no comércio da cidade de Monte Aprazível.

Em seu depoimento na fase policial, a vítima informou o furto do seu cartão e senha, praticado no dia 08.02.2011, por uma mulher de pele branca, com aproximadamente quarenta e três anos, de compleição física forte, com um dos braços enfaixados. Quando procurou seu cartão no dia 11.02.2011 e não o encontrou, foi até a agência bancária comunicar o ocorrido, quando o funcionário Fabio lhe informou acerca dos empréstimos, transferências compras e saques realizados nos dias 09 e 10

de fevereiro de 2011, sendo então bloqueada sua conta corrente. Com relação às demais testemunhas ouvidas em juízo, verifica-se que apesar de transcorrido grande lapso temporal da ocorrência dos fatos, mais de dez anos, a maioria delas confirmou seus depoimentos prestados na fase inquisitiva de forma firme e coerente acerca dos fatos. Todas as testemunhas confirmaram seus depoimentos ofertados na Delegacia de Polícia e o reconhecimento fotográfico. O funcionário da agência bancária, Fábio Pastore Rodrigues, afirmou em seus depoimentos que após ser informado pela vítima o furto de seu cartão e senha, verificou a realização de várias movimentações financeiras na conta corrente, entre os dias 09 e 10 de fevereiro de 2011, como empréstimos, saques, transferências e compras na função débito.

Da mesma forma o investigador de polícia José Rodrigo Tonon, confirmou em juízo toda a dinâmica dos fatos apurados em seu Relatório de Investigação de fls. 11/12, quando informou que após o furto do cartão e da senha, os indivíduos primeiramente efetuaram transferência de valores para uma conta em Guaíra, de titularidade de Elisa Mara de Oliveira. Através de contato com policiais da cidade de Guaíra foram fornecidas imagens de Elisa e Alfredo, sendo eles reconhecidos por funcionários do comércio de Monte Aprazível, quando entraram em três lojas. Em uma delas, tinha filmagens de uma pessoa com o braço enfaixado, que correspondia a Elisa e também mais um homem e uma mulher. Os funcionários da loja Cergatti reconheceram Alfredo, que teria adentrado a loja para comprar um tênis, na posse do cartão. Os funcionários reconheceram o réu através de fotografias, obtidas com a delegacia de Guaíra, de onde Alfredo e Elisa já eram conhecidos pela prática de estelionato. Do mesmo modo, as três funcionárias da Loja Cergatti de Monte Aprazível, que atenderam a senhora e dois rapazes quando faziam compras, prestaram depoimentos consistentes acerca da autoria delitiva do réu.

As três testemunhas diretas, na fase policial, descreveram as características das pessoas que foram realizar compras no estabelecimento comercial, reconhecendo fotograficamente o acusado (c. f. Autos de Reconhecimentos Fotográficos de fls. 65, 67 e 69). Em juízo, confirmaram seus depoimentos na delegacia e os reconhecimentos fotográficos feitos por elas, e ainda, Maíza e Jucileia confirmaram que foi o homem quem efetuou o pagamento das compras.

Destaco que, apesar de em juízo as testemunhas não se recordarem com detalhes dos fatos ocorridos há dez anos, isto não enfraquece seus relatos, sendo plenamente aceitável a existência de alguns lapsos de memória. Ademais, todas confirmaram seus depoimentos na fase extrajudicial, ofertados em data próxima aos fatos.

Quanto ao réu, na fase policial permaneceu em silêncio (fls. 151). Depois disto, por quase dez anos sendo procurado, inclusive no endereço que indicou na delegacia de polícia, não foi encontrado.

Sua defesa alegou injusta a aplicação de revelia proferida na audiência de fls. 642/643, e requereu a aplicação de nulidade do ato, sob o argumento de que não ocorre a revelia quando o réu é citado por edital e não comparece.

Ocorre que em 19.04.2021, o réu compareceu espontaneamente ao feito, através de procurador constituído, apresentando procuração datada de 24.05.2019 (fls. 518), devidamente assinada por ele, mas sem declinar seu atual endereço.

Instado o procurador a apresentar o endereço de seu representado, foi por ele informado às fls. 533 que não sabia informar o atual domicílio de Alfredo, e que mantém contato com ele através de parentes e familiares.

Portanto, o comparecimento espontâneo do réu através de procurador constituído tornou possível o prosseguimento do processo, comprovando-se o conhecimento dele pelo réu.

Em seguida, o réu foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, na pessoa de seu procurador, conforme publicação no DJE de fls. 570, mas não compareceu à audiência, demonstrando total desinteresse em ser ouvido pelo juízo.

Sendo assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, não sendo o caso de afastar-se a revelia do réu, uma vez que intimado através de seu procurador com amplos poderes para representá-lo em juízo, não compareceu em juízo para seu interrogatório, tampouco apresentou motivo justificado.

Não bastasse, em observância aos ditamos da boa-fé objetiva, incide no caso o estabelecido no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para sua existência.

No tocante à alegação defensiva de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ante o não cumprimento das exigências contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, também não merece prosperar.

Isto porque, conforme se verifica dos autos às fls. 65, 67 e 69, na delegacia de polícia foram apresentadas às funcionárias da Loja Cergatti, Maiza Arnais Miami, Claudia Maria Alipio Peredo e Jucileia Alves de Lima, duas fotografias, sendo uma de uma mulher e outra de um homem. Todas as três funcionárias reconheceram apenas o réu como sendo a pessoa que efetuou o pagamento da compra com o cartão de crédito no dia da compra no estabelecimento comercial.

Ressalta-se que os reconhecimentos foram lavrados no dia 04.03.2011, ou seja, há poucos dias da ocorrência dos fatos, que se deu em 09.02.2011, ocasião em que os fatos estão claros nas lembranças das pessoas.

De fato, o artigo 226 do Código de Processo Penal, dispõe sobre as formalidades a serem aplicadas no reconhecimento fotográfico :

“Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

No entanto, mesmo que tais formalidades não tenham sido observadas, não macula a ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e simplesmente fornece ao titular da ação penal notícias sobre indícios de materialidade e de autoria.

Ou seja, as disposições insculpidas no artigo 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. Neste sentido é a jurisprudência atual do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo :

“FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Concurso de agentes e fraude. Apelos dos réus Lucas, Isabela e Welinton. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Acusados identificados como os responsáveis pela infração. Inobservância das regras previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, que não torna a prova inválida, por se tratar de mera recomendação legal. Reconhecimento fotográfico válido, servindo como mais um elemento de convicção para amparar o desfecho condenatório. Condenações mantidas. Dosimetria. Sanções fixadas nos pisos legais em relação a Lucas, compensada a atenuante da confissão com a agravante da idade da vítima (idoso). Quanto a Isabela, reprimendas elevadas de um sexto, em razão da referida agravante. No tocante a Welington, portador de maus antecedentes, básicas aumentadas de um sexto. Na segunda etapa, elevação de um terço das sanções por conta da dupla reincidência e da agravante da idade da vítima. Lucas e Isabela beneficiados com a substituição das corporais por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto. Quanto ao corréu Welinton, mantido o regime fechado. Apelos improvidos”. (TJSP, Apelação Criminal nº 0011723-27.2018.8.26.0344, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : Tristão Ribeiro. São Paulo, 02 de maio de 2022). (grifo meu).

Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à mera

recomendação do procedimento de reconhecimento fotográfico, em caso de haver outros elementos probatórios:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 695650 / SP, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2021/0306149-0. Relator : Ministro Ribeiro Dantas. Data do julgamento : 24.05.2022). (grifo meu).

No caso dos autos, a autoria delitiva imputada ao réu não está corroborada apenas nos reconhecimentos fotográficos, mas também em provas testemunhais demasiadamente significativas, embasadas nos depoimentos do investigador polícia e das funcionárias da Loja Cergatti que atenderam a compra e presenciaram o uso do cartão da vítima pelo réu.

Ademais, as três testemunhas diretas conseguiram reconhecer o réu na delegacia de polícia, e confirmaram em juízo a validade do reconhecimento fotográfico feito na fase policial.

Noto que o relatório de investigação (fls. 11/12) descreve a dinâmica dos fatos, e as informações colhidas à época acerca das compras feitas na Loja Cergatti, em que as três funcionárias informaram ao policial que no referido estabelecimento foram dois homens, um moreno, baixinho e outro moreno claro, alto e uma mulher morena, de cabelos pretos compridos, com tatuagem nas costas, onde aparentavam apressados e pagaram com cartão em nome da vítima.

As duas compras feitas pelos indivíduos e pagos pelo réu na referida loja, utilizando o cartão da vítima, encontram-se comprovadas no Extrato Bancário da vítima de fls. 14, onde indica as compras feitas no dia 09.02.2011, às 12:12 e 12:18 horas, na Loja Cergatti, em valores de R\$ 549,00 e R\$ 390,00.

No mais, os argumentos para a absolvição do réu apresentados na combatida defesa não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Na realidade, a situação é característica do delito de estelionato, pois a intenção do réu foi de obter vantagem econômica indevida, pois, com o o cartão de banco da vítima, efetuou duas compras, causando em prejuízo para a vítima, no valor total de R\$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais).

Por outro lado, a imputação apresentada na denúncia da prática de quatorze estelionatos pelo réu não restou demonstrada.

De fato, conforme o Extrato Bancário da vítima de fls. 13/15, há indicação de que nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro de 2011, ocorreram várias transações como empréstimos, transferências, saques e compras em estabelecimentos bancários.

No entanto, apenas as funcionárias da Loja Cergatti reconheceram o réu como pessoa que utilizou o cartão da vítima. Os demais funcionários de outras lojas indicadas na denúncia, como “Lojas Longo” e “A Paulistana” não confirmaram o reconhecimento

fotográfico. Isto se verifica nos reconhecimentos fotográficos negativos dos funcionários da Loja Longo, Douglas Medeiros Barbosa, Simone Lopes Domine e Jane Cavallari, de fls. 57, 59 e 61, e do funcionário da loja A Paulistana, Aparecido Alves Martins de fls. 63.

Também não se logrou êxito em comprovar que foi o réu quem realizou os empréstimos bancários, saques e transferências bancárias da conta da vítima, uma vez que a dinâmica dos fatos, demonstram que quem furtou o cartão da vítima foi Elisa, e que existiam outros indivíduos participando das fraudes, havendo, inclusive até transferências bancárias realizadas para a própria conta bancária de Elisa Mara Oliveira.

Ainda, das imagens encartadas às fls. 16/21 e 23/25, nitidamente se constata a participação de outras pessoas na prática dos estelionatos.

Sendo assim, não restou comprovado que era só o réu quem manejava o cartão da vítima, devendo ser absolvido da imputação de doze vezes da prática de estelionato, por falta de provas.

Assim, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, restou demonstrada a prática de dois estelionatos pelo réu, referente as duas compras realizadas na Loja Cergatti, fazendo-se passar pela vítima ou que havia obtido a posse e a senha do cartão bancário dela de forma lícita.

Caracterizada também a continuidade delitiva constante do artigo 71 do Código Penal, que é quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie e que guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

A percepção da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é nesta direção em caso semelhante :

"Apelação. Furto qualificado e estelionato. Provas suficientes para a condenação. Pedido de desclassificação para furto simples. Improcedente. Saques em caixa eletrônico utilizando cartão e senha intransferíveis, de propriedade da vítima. Meio de execução que inibe a segurança do sistema bancário, permitindo a subtração. Manutenção da qualificadora. Estelionato. Funcionários de estabelecimentos comerciais induzidos a erro em virtude de ter a ré se feito passar pelo proprietário do cartão de crédito. Capitulação legal correta. Impossibilidade de aplicar a continuidade delitiva entre delitos de espécies diferentes e cujos meios de execução foram diversos. Manutenção do quantum sancionatório. Penas substitutivas. Ausência de fundamentação quanto às duas restritivas de direitos em detrimento de uma restritiva e uma multa. Prevalência da opção mais benéfica ao acusado. Recurso a que se dá parcial provimento". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500382-64.2019.8.26.0482, da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : Amable Lopes Soto. São Paulo, 29 de outubro de 2021). (grifo meu).

Logo, o conjunto probatório apresentado nos autos, mostra-se convincente de que o réu obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio.

Neste contexto, conclui-se pela parcial procedência da denúncia, pois demonstrada a prática de dois delitos de estelionato.

Portanto, para além de revestida de tipicidade, a conduta perpetrada pelo denunciado caracteriza-se como ilícita e culpável, por não abarcada por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por conseguinte, a configuração da infração penal de estelionato, mostra-se evidente, sendo de rigor a condenação.

DOSAGEM DA PENA

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, a conduta da vítima e as consequências do crime, são elementos a serem considerados na aplicação da pena.

A pena para o delito do artigo 171, caput, do Código Penal é de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.

Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da aplicação da pena, observo que o réu ostenta extensa ficha de antecedentes criminais, com cerca de 21 folhas dos autos (fls. 620/641), demonstrando personalidade voltada à prática de delitos, bem como conduta social reprovável. A maioria dos processos encontram-

se suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em razão da dificuldade de localização do réu, como ocorreu nestes autos. Por tal, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), passando a ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico ausentes atenuantes da pena. Presente, porém, a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, em razão do delito ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos. Sendo assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando a ser fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena. Presente, no entanto, a causa de aumento da pena em razão da continuidade delitiva constante do artigo 71, caput, do Código Penal, tendo em vista a comprovação de dois estelionatos pelo réu. Em razão disto, aplica a pena de um só dos crimes, com o aumento de 1/6 (um sexto), passando a ser fixada em definitivo em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considero como o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao disposto no artigo 60 do Código Penal, diante da falta de informação sobre a condição econômica do réu.

Em atenção aos parâmetros do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, considerando que a pena é inferior a 04 anos e não sendo o réu reincidente, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Sopesando a personalidade do réu, voltada à prática de delitos, conforme sua vasta folha de antecedentes criminais (fls. 620/641), a grande dificuldade de sua localização nos autos, apesar de ter sido interrogado na fase policial e não mais encontrado no endereço lá indicado, e ter apresentado procuração nos autos sem indicar seu atual endereço (fls. 518), demonstrando comportamento que não corresponde à boa-fé processual, inclusive mostrando impasse no eventual cumprimento da pena, verifico que ele não preenche os requisitos subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, portanto, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos.

Inaplicável também a suspensão condicional da pena porque não preenchidos os pressupostos legais constantes do artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE a presente ação penal para :

a) JULGO PROCEDENTE para condenar o réu ALFREDO APARECIDO ARANTES, como incurso, por duas vezes, no artigo 171, caput, c. c. o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. O valor da pena de multa é de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, atualizado quando da execução.

b) JULGAR IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVER o réu ALFREDO APARECIDO ARANTES de doze delitos de estelionato imputados na denúncia, ou seja, por doze vezes no artigo 171, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com relação à pena de multa, deverá ser executada no juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que alterou o artigo 51 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva em nome do réu; b) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; e c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Neves Paulista, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA